

1501114-77.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... fato de o local ser próximo de um ponto de tráfico. Questionado, o indivíduo falou que furtou os objetos de uma residência em construção e informou o endereço, para onde seguiram. Disse que, na obra, encontrou os dados do proprietário e fizeram contato com ele, que reconheceu os objetos furtados como sendo dele. No mesmo sentido o depoimento do guarda civil Pedro Carlos, ouvido a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501114-77.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000958

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201314/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 26341322 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2201314 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIEUDO DE BRITO VIEIRA

Réu Preso

Aos 29 de novembro de 2022, às 16:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: FRANCIEUDO DE BRITO VIEIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Vítima: F.J.C. - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC PEDRO CARLOS GIRHÃO - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos da testemunha GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA e da vítima F.J.C..

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC PEDRO CARLOS GIRHÃO, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC PEDRO CARLOS GIRHÃO, o que foi homologado pela MMª. Juíza. Após, o réu FRANCIEUDO DE BRITO VIEIRA foi devidamente interrogado. O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "FRANCIEUDO DE BRITO VIEIRA, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 67/69. O processo teve andamento regular. Devidamente citado (fls. 88/89), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 93/94), sendo a denúncia recebida (fls. 77/78 e 95/97). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus, por fim, interrogados. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), fotografias de fls. 18 e pela prova oral coligida. A autoria do crime descrito na denúncia restou também suficientemente comprovada. O representante da vítima, Fábio Jorge Correa, narrou que é engenheiro civil e estava realizando uma ampliação da residência local dos fatos, que estava já totalmente cercada e murada, somente não tendo ainda sistema de alarme. Na data dos fatos, foi comunicado, através da Guarda Civil, que um indivíduo havia furtado objetos da obra em comento. Aduziu que compareceu na delegacia e reconheceu os bens e materiais furtados e encontrados com o acusado. Por fim, afirmou que constatou no local sinais de arrombamento do portão da obra. Confirmou que as fotografias apostas no laudo de fls 115/119 são do local dos fatos. O guarda municipal Joel Vasconcelos De Lima asseverou que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina pela Rua Dom Manoel quando, por volta das duas horas da madrugada, avistou o acusado andando sozinho por uma via escura. Aduziu que o réu estava empurrando uma carriola coberta e, desconfiando da situação, realizou a abordagem. Constatou a presença de várias ferramentas e outros objetos no interior da carriola e, uma vez questionado, o réu, informalmente confessou que havia furtado os objetos de uma casa em obras, tendo levado os guardas ao local indicado. Acrescentou que o acusado informou disse ter forçado o portão e pulado uma mureta, tendo subtraído os objetos do quintal. Asseverou que compareceu ao local e constatou tratar-se de uma residência em reforma, sendo que seu portão estava forçado. Finalmente, asseverou ter encontrado o número do telefone do responsável pela obra e realizou contato para comparecimento da delegacia de polícia. Por fim, o guarda afirmou que no local havia sinais de arrombamento do portão, conforme descrito pelo próprio acusado. No mesmo sentido foram as palavras do guarda municipal Pedro Carlos Girhão, ouvido apenas na fase policial. Interrogado, o réu confessou parcialmente os fatos, confirmando que ingressou no local dos fatos e de lá subtraiu os bens descritos na denúncia. Disse, entretanto, que o portão já estava aberto que lá adentrou, e que não arrombou qualquer cadeado ou forçou o portão. Reconheceu a fotografia de fls. 116 e 117 como sendo o local onde praticou a subtração. Assim, ante a confissão do acusado, que foi corroborada pelo restante do álbum probatório, tem-se que a autoria do crime é certa na pessoa do acusado, sendo sua condenação de rigor. Outrossim, a qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo também restou bem comprovada, tanto pela prova oral, eis que o representante da vítima e o guarda municipal ouvido confirmaram que havia sinais de arrombamento do portão, assim como pelo laudo peciaial acostado aos autos, o qual foi confirmado tanto pela vítima quanto pelo próprio acusado como sendo o local do furto objeto deste processo. Por fim, é certo que o crime ocorreu por volta das duas horas da madrugada, durante o repouso noturno, devendo ser a causa de aumento reconhecida. Destarte, tem-se que o crime descritos na denúncia restaram bem comprovados, sendo a condenação de rigor. Na dosimetria da pena, em observância ao disposto no art. 59 do Código

Penal, verifico que, na primeira fase, as circunstâncias são neutras. Na segunda fase, o réu é reincidente, inclusive específico (autos nº 1512852-90.2021.8.26.0019 - fls. 70; nº 0001339-50.2017.8.26.0599 - fls. 70/71; 0001339-50.2017.8.26.0599 - fls. 71), razão pela qual a pena deve ser fixada acima do mínimo legal. Na última fase, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, pois o crime fora praticado durante o repouso noturno. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, na forma como descrito na inicial. Encerrada a instrução probatória, verifica-se que deve ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Com efeito, Excelência, não há a presença de um conjunto probatório robusto que autorize a prolação de uma sentença condenatória. Nesta data, a vítima Fabio declarou que realizava uma obra no local dos fatos. Recebeu uma ligação durante a madrugada e foi até a Delegacia. A obra fica na Rua Joaquim André, 1107. O local estava cercado e murado. Acredita que o cadeado do imóvel foi arrombado. Foi exibida a imagem contida no laudo técnico. A vítima confirmou que se tratava do local dos fatos. A testemunha Joel, GCM, declarou que estavam em patrulhamento quando, por volta das 02h da madrugada, visualizaram o acusado carregando uma carriola com várias ferramentas. Por conta disso, efetuaram a abordagem do réu. Ao ser questionado sobre os objetos, o acusado disse que furtou os bens de uma residência em construção. Foram ao local dos fatos e constataram a ocorrência da subtração. Fizeram contato com o proprietário do imóvel e ele reconheceu a propriedade dos objetos. Havia sinal de arrombamento no portão do imóvel. O acusado também escalou um muro. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que teve uma recaída no uso de drogas, por isso praticou o furto. Porém, não arrombou nada, o portão estava aberto e o cadeado estava colocado em lugar errado. Depois da sua abordagem, indicou para os Guardas o local de onde tinha retirado os objetos. Foi exibida a imagem do imóvel ao réu. O acusado confirmou que efetuou o furto do imóvel e disse que o portão menor da residência estava aberto. Não forçou o portão para entrar, tanto que o cadeado não apresentava sinais de arrombamento ou arranhões. Quem fechou o imóvel cometeu um erro e deixou o local aberto. Excelência, em que pese o acusado ter reconhecido, ainda que de forma parcial, a prática dos fatos, sua confissão, como qualquer outra prova, possui valor relativo e deve ser corroborada pelo restante das evidências dos autos. Em relação ao depoimento da vítima, a sua qualidade de ofendido o torna diretamente interessado na solução da causa, de modo que o abalo provocado pelo crime poderá levá-la a incorrer em erro pela vontade que tem de reconhecer o autor dos fatos. Além disso, a vítima não presenciou a prática da subtração, de modo que seu depoimento pouco contribuiu para a construção da verdade processual. De outra parte, quanto aos Guardas Municipais, verifica-se que seus depoimentos invariavelmente são exarados sem a isenção que deles se espera. Suas assertivas no processo, dada a evidente parcialidade que as permeia, não exercem sua função precípua, qual seja: a de explicitarem uma fotografia neutra da realidade não presenciada pelo Magistrado. Neste ponto, cabe ressaltar que a Defensoria Pública também não afirma que o GCM mentiu em juízo, apenas que reproduziu a sua percepção dos fatos, naturalmente influenciada por sua condição de órgão da segurança pública. Assim sendo, percebe-se que não há substrato probatório mínimo que comprove a autoria delitiva, pelo que o réu deve ser ABSOLVIDO, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso assim não entenda Vossa Excelência, pugna a Defensoria Pública, então, pelo AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. Isso porque, quanto ao repouso noturno, causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro do art. 155 do Código Penal, tem-se que a intenção do legislador em inseri-la no contexto do crime patrimonial de furto foi atribuir maior proteção jurídica à esfera de descanso do titular (fático ou jurídico) do patrimônio objeto do crime. O reduto de descanso das pessoas, naturalmente, é a residência, cuja proteção jurídica advém desde a Constituição Federal, especialmente no que toca ao disposto no art. 5º, inciso XI, no sentido de que "a

casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Ocorre que a conduta versada nos autos, com a máxima vênia, não guarda pertinência com a incidência da referida causa de aumento de pena, sobretudo porque os fatos, supostamente, teriam ocorrido em um estabelecimento comercial. Ademais, é entendimento pacífico que a causa de aumento em questão NÃO se aplica à modalidade qualificada do furto, pela topografia legal. Inclusive, em relação às inúmeras divergências a respeito do assunto, cumpre observar que, recentemente, a 3ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o sistema de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087), afastou a aplicabilidade da referida causa de aumento ao furto qualificado, sendo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.039, determina que a referida decisão possui caráter vinculante e deve ser observada pelas E. Instâncias Inferiores. Dessa forma, a causa de aumento em questão merece ser afastada. Requer-se, também, na hipótese de condenação, o AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Excelência, em relação ao rompimento de obstáculo, por se tratar de uma qualificadora que deixa vestígios, é imprescindível que ela seja efetivamente demonstrada por prova técnica apta a atestar a sua ocorrência, não sendo possível o seu reconhecimento com base em meras declarações de testemunhas ou até mesmo em eventual confissão do acusado, nos termos do Código de Processo Penal. Ocorre que, no caso em pauta, a despeito da realização da perícia no imóvel, o laudo juntado aos autos atestou que, na ocasião do crime, não foram encontrados vestígios de rompimento de obstáculo, eis que o portão do imóvel, na realidade, estava ABERTO. Portanto, a qualificadora em questão deve ser afastada. Por fim, na hipótese de condenação do acusado, no tocante à dosimetria da pena, a Defensoria Pública pugna pela: 1) fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao tipo penal, devendo a sua vida pregressa ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar o bis in idem com eventual agravante da reincidência; 2) na segunda fase da dosimetria, postula-se pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; 3) a fixação do regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c" e § 3º, do CP, ou como decorrência da regra do art. 387, § 2º, do CPP, ressaltando-se que o C. STJ já editou enunciado de súmula no sentido da possibilidade de fixação de regime menos rigoroso até para o réu reincidente; 4) seja assegurada a possibilidade do acusado aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize a manutenção de sua prisão preventiva (art. 312 do CPP)".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

FRANCIEUDO DE BRITO VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 02h10min, na Rua Dom Manoel, nº 1067, Bairro Jardim Ibirapuera, nesta cidade e comarca de Piracicaba, durante repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, as ferramentas e os objetos descritos no auto de exibição e apreensão e entrega de fls. 15/17, e demonstrados pela fotografia de fls. 18, avaliados em R\$ 2.995,00, pertencentes ao proprietário do imóvel em obra vítima, representado pelo engenheiro civil Fábio Jorge Corrêa.

Narra a denúncia que o acusado, já imbuído do propósito de saquear patrimônio alheio, deslocou-se até o local dos fatos, arrombou o portão de entrada do imóvel, subtraiu as sobreditas ferramentas e objetos e se evadiu do local. Ocorre que guardas municipais estavam em patrulhamento pelas imediações do local dos fatos, quando visualizaram FRANCIEUDO transportando a res furtiva em uma carriola aberta e abordaram-no. Indagado, o réu confessou informalmente a prática delitiva. Na delegacia, o engenheiro civil reconheceu, sem sombra de dúvidas, as ferramentas e os objetos apreendidos na posse de FRANCIEUDO como sendo de propriedade do imóvel

em obra sob sua responsabilidade.

Recebida a denúncia em 05.08.2022 (fls. 77/78), o réu foi citado pessoalmente (fls. 89), apresentou a defesa preliminar (93/94), seguindo-se a decisão que manteve o recebimento da denúncia (fls. 95/97).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante vítima e testemunha arrolada na denúncia. Após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do acusado.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

09/14, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/17, pela fotografia de fls. 18 e pelo laudo pericial de fls. 115/119.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 05/06).

Em juízo, disse que tinha recaído no uso de drogas, passou pelo local, viu o portão aberto, adentrou no imóvel e pegou os os objetos para comprar drogas. Asseverou que não arrombou nenhum portão.

O representante da vítima, ouvido na fase policial, declarou que é engenheiro civil e estava realizando a ampliação de uma residência no local os fatos, que, portanto, estava em obras. Disse que foi comunicado pela Guarda Civil de que um indivíduo havia furtado objetos da obra e compareceu à Delegacia, onde, ao visualizar os materiais furtados, reconheceu-os como sendo pertencentes a seus clientes, porquanto é o responsável pela construção e quem realiza a compra dos materiais.

Em juízo, reiterou suas declarações. Esclareceu que o endereço correto da obra é Rua Joaquim André, 1107, e reconheceu as fotos que instruem o laudo de fls. 115/119 como sendo do local dos fatos.

O guarda municipal Joel relatou que estavam em patrulhamento e visualizaram um indivíduo carregando uma carriola com várias ferramentas, o que chamou a atenção da equipe em razão do horário e do fato de o local ser próximo de um ponto de tráfico. Questionado, o indivíduo falou que furtou os objetos de uma residência em construção e informou o endereço, para onde seguiram. Disse que, na obra, encontrou os dados do proprietário e fizeram contato com ele, que reconheceu os objetos furtados como sendo dele.

No mesmo sentido o depoimento do guarda civil Pedro Carlos, ouvido a fls. 02.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E “como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665).

Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068,

Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado: "Habeas Corpus – Tráfico de drogas– Pleito de revogação da prisão preventiva – Alegação de ilegalidade da prisão realizada por Guardas Municipais. Atuação dos Guardas Municipais. Ausente ilegalidade – Artigo 301 do CPP – Qualquer pessoa do povo pode, e as Autoridades policiais e seus agentes devem realizar prisões em flagrante – Crime de Tráfico de Drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Jurisprudência do C. STJ. No caso em tela, ao que consta, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. No mais, eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente.

Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2014342-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Não bastasse essa orientação já consolidada na jurisprudência, há que se ressaltar que, conquanto não seja essa essencialmente sua função, o guarda municipal está autorizado por norma legal expressa a encaminhar à presença da autoridade policial indivíduos presos em flagrante delito, consoante a regra inscrita no artigo 5º, inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

O recente entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a prisão em flagrante perpetrada por guardas municipais é nula sempre que desenvolverem ação pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo e atividade investigativa, por violação de suas atribuições constitucionais, não é aplicável nos casos, como o dos autos, em que os guardas municipais deparam-se com situação de flagrante que não envolve as atribuições próprias das Polícias Civil e Militar.

E a apreensão de coisa produto de crime em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado (Revisão Criminal nº 0297742-32.2009.8.26.0000, Rel. Des. Aguinaldo de Freitas Filho, j. 28.6.12).

Nesse contexto, de rigor a condenação, nos termos da denúncia: o réu foi detido logo após a prática do delito, nas proximidades do local dos fatos, em poder dos objetos subtraídos, e não apresentou justificativa plausível para os fatos.

Observo que a hipótese é mesmo de furto consumado.

Com efeito, a prova produzida atesta que o réu foi abordado por guardas civis quando caminhava na via pública, já na posse dos objetos subtraídos.

A propósito do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, firmou tese jurídica para os fins do art. 1.036 do novo Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro – j. 14.10.2015).

A qualificadora descrita na denúncia não ficou caracterizada, porquanto o laudo pericial atestou que não houve arrombamento, eis que o portão não estava trancado e foi apenas aberto (fls. 115/119).

O furto ocorreu às 02h10min.

Reverso posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento da referida majorante não é necessário que o crime tenha sido praticado em local habitado ou não, bastando, para sua configuração, que tenha ocorrido no período noturno, ocasião em que a vigilância é menos eficiente e maior a vulnerabilidade do patrimônio, merecendo reprovação mais severa. Com efeito, o furto é crime contra o patrimônio e a lei não faz referência ao local do crime, não podendo se reputar determinante para a configuração dessa causa de aumento da pena que o imóvel esteja habitado, com pessoas repousando.

Nesse sentido precedentes do STJ: "Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - CP é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública" (AgRg nos EDcl no REsp 1793735/SP, , DJe 04.06.2019).

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime" (AgRg no REsp 1851700/DF, Rel Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 22.9.20).

2. Passo à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, verifico que o réu é reincidente. Entretanto, esse fato somente pode ser considerado na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da fixação da pena, tem-se que o réu é reincidente, inclusive específico (proc. nº 0001339-50.2017 da 1ª Vara Criminal local - cf. cert. de fls. 70/72). De outro lado, o réu confessou a prática do crime, razão pela qual, reputando equivalentes as circunstâncias agravante e atenuante, mantenho a pena-base fixada.

Presente a causa de aumento do repouso noturno, elevo a pena em um terço, resultando um ano e quatro meses de reclusão e treze dias-multa. Não há causas de redução.

Em razão da reincidência, o réu não faz jus à substituição prevista no art. 44 do Código Penal, nem a concessão de "sursis".

Não obstante a reincidência específica, considerando as circunstâncias do crime, o disposto pela Súmula n. 269 do STJ e o tempo de prisão cautelar, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, valendo observar que o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória pela prática de crime doloso.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a perseguição criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

3. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar FRANCIEUDO DE BRITO VIEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, "caput", c.c. parágrafo 1º, do Código Penal, à pena de um ano e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime

semiaberto para início de cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

.

2) Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD, SARC e TRE.

3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

4) Tratando-se de multa cumulativamente aplicada, providencie-se inserção do valor atualizado no sistema informatizado, consignando-se o montante de R\$523,71, equivalente a 16,38 UFESPs, oportunamente abrindo-se vista ao Ministério Público para as providências cabíveis.

5) O réu foi assistido por Defensor Público, logo, está isento das custas processuais.

6) Regularizados os autos, archive-se com a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", nos termos do Art. 480, §1º, das NSCGJ.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]